

1501348-93.2018.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandre Torres de Aguiar

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... que se prove o contrário.

Cálculo da Pena - Tráfico de Entorpecentes - Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido - Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Criminal

Rua Jacob Emmerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501348-93.2018.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501348-93.2018.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NICOLAS ORIGUELA MENEZES BADINI

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Torres de Aguiar

Vistos.

NICOLAS ORIGUELA MENEZES BADINI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na inicial, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 77 porções de cocaína, 26 pedras de crack, e 5 porções de maconha, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica. Foi também apreendida com o réu a quantia de R\$157,00.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia, foi o réu citado.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e, ao final, foi o réu interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação para a condenação do réu, nos termos da denúncia, diante da prova produzida.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, pela insuficiência de provas.

Subsidiariamente, formulou pedidos relativos à fixação da pena.

Adveio sentença condenatória e dela a Defesa recorreu.

Na instância superior, por maioria de votos, deu-se parcial provimento ao apelo defensivo para, mantida a condenação do acusado, reduzir suas penas a (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 199/208). Opostos Embargos Infringentes, por maioria de votos, o recurso foi rejeitado (fls. 275/280).

Da decisão que não admitiu o Recurso Especial interposto pela Defesa (fls. 318/319), foi interposto pela Defesa Agravo em Recurso Especial.

Conhecido o Agravo, foi dado provimento ao Recurso Especial para reconhecer-se o direito do acusado à consideração da aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e modulação da fração a ser fixada, com análise, outrossim, da possibilidade de conversão da pena corporal em restritiva de direitos e do regime inicial adequado à nova pena fixada.

É o relatório.

DECIDO.

A presente sentença é proferida em estrito cumprimento ao que foi decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça ficando ressalvado, com a devida vênia, o entendimento deste Juízo sobre a matéria.

Ademais, para que restes consignados todos os elementos já devidamente apreciados anteriormente, transcreve-se abaixo a fundamentação da sentença já proferida por este Juízo, uma vez que servirá de base para o cumprimento do que foi imposto pelo C. Superior Tribunal de Justiça para dosimetria da pena.

"A ação penal é procedente.

A materialidade do delito ficou comprovada através do auto/ de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do auto de exibição e apreensão, do auto de constatação, do laudo pericial, bem como pelo conjunto probatório constante dos autos.

Também não restam dúvidas quanto à autoria do delito.

Interrogado em Juízo, o acusado negou a prática do delito. Disse que estava no ponto final de lotação e que ao lado há um bar. Aguardava a lotação chegar quando um veículo parou para pedir-lhe informação e saiu rapidamente do local. No momento em que o veículo saiu, os policiais se aproximaram em motocicletas. Foi abordado e uma viatura foi acionada. Já na viatura, os policiais constataram que já possuía problemas com a Justiça e então foi levado à delegacia. Alegou que nada foi encontrado consigo e as drogas lhe foram apresentadas na delegacia.

Entretanto, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado, evidencia-se a realização do tráfico. Além disso, a versão por ele apresentada em Juízo não é crível em face do restante das provas produzidas durante o processo. A testemunha policial militar Eduardo, ouvida sob o crivo do contraditório, relatou que realizavam patrulhamento em motocicletas e, ao virar a rua, viram o réu servindo um carro. O veículo saiu do local e não foi possível ver a placa, pois era noite e estava serenando. Realizada a abordagem do acusado e a busca pessoal, em seu bolso direito foram encontradas as drogas em uma sacola e, em seu bolso esquerdo, cerca de cem a cento e cinquenta reais em dinheiro. Não se recordou da quantidade exata de entorpecentes apreendidos, relatando tratar-se de média quantidade, havendo cocaína e maconha. Declarou que avistou o acusado a uma distância que acredita ser de cinquenta metros e não soube dizer se as viaturas foram avistadas, pois o veículo servido pelo réu estava direcionado para o lado oposto. Após a saída do automóvel, o acusado permaneceu no local sozinho. Consignou que havia outras pessoas pelo local, pois há um comércio de bebidas e cigarros próximo. Esclareceu que o réu não estava exatamente defronte a esse comércio, mas, sim, a poucos metros para o lado. O réu, informalmente, admitiu que a droga era de sua propriedade, mas sem dizer para qual finalidade. Relatou que o local dos fatos é conhecido como ponto de venda de drogas. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos.

No mesmo sentido, a testemunha policial militar Anderson, ouvida em Juízo, narrou que realizavam patrulhamento pelo bairro Humaitá e, ao adentrarem uma rua, avistaram o acusado debruçado sobre um veículo, servindo-o. Ao perceber a presença policial, o veículo se evadiu e não foi possível identificar o automóvel pelo seu emplacamento. O acusado foi abordado e, em um dos bolsos de sua jaqueta, havia uma

sacola com drogas e, no outro bolso, a quantia de R\$ 157,00 em dinheiro. As drogas consistiam em 77 porções de cocaína, 26 pedras de crack e 5 porções de maconha. O réu nada declarou sobre a droga e o dinheiro com ele encontrados. Disse que quando da abordagem, havia diversas pessoas em um bar, sendo que também há um ponto de lotação do lado oposto da rua. Esclareceu que o local em que o acusado foi abordado era quase em frente ao bar. Declarou que o local dos fatos é conhecido como ponto de venda de drogas. Disse que estava a uma distância de aproximadamente vinte e cinco metros quando avistou o acusado servindo o veículo. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado, no que se refere ao tráfico de drogas, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra das testemunhas policiais militares, que de maneira segura, uniforme e convergente, descreveram com detalhes como ocorreu a abordagem do acusado e a apreensão da droga.

Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade do testemunho policial.

Como já se decidiu "é bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando ele fosse convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor, aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade" (Apelação criminal nº 112.195-3/1, Santos, Rel. Des. Canguçu de Almeida, em 07/10/1991, 2ª Câmara Criminal).

Aliás, mostra-se "imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que o depoimento de policiais responsáveis pela segurança pública, não podem ser desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem função de salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento" (TJSP - AP - Rel. Walter Guilherme - j. 10.03.98 - JTJ 214/284).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já teve oportunidade de manifestar-se favoravelmente à validade desses depoimentos. A propósito, registro: "Tóxicos - Tráfico - Prova testemunhal: Depoimento de policiais. A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente" (STF - 2ª T. - HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Correa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

"Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF 1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Mm. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO INCORRETO. MENORIDADE RELATIVA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO À MÍNGUA DE PEDIDO NO RECURSO MINISTERIAL. REGIME FECHADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada em poder do réu.

2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10).

3. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminoso. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Cezar Peluso – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Luiz Fux – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).

4. Dosimetria da pena estabelecida de modo incorreto. Menoridade relativa. Correção de ofício.

5. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminoso. Precedentes do STF (HC 121.057/SP – Rel. Min. Luiz Fux – j. 25.02.14 – DJU 18.03.14; HC 118.380/SP – Rel. Min. Teori Zavascki – j. 04.02.14 – DJU 14.02.14; HC 116.541/ES – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 21.05.2013 – DJE 06.06.13; HC 109.236/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 13.12.11 – DJU 14.23.12). Manutenção à míngua de pedido no recurso Ministerial.

6. O regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de tráfico de drogas será

o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

7. Provimento do recurso do Ministério Público e correção, "ex officio", da dosimetria da pena." (Ap. nº 3003382-41.2013.8.26.0471; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Porto Feliz; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 01/06/2016; Data de registro: 07/06/2016) (grifo nosso)

"Tráfico de entorpecentes - Agente que mantém em depósito e guarda substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda - Caracterização

Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e de "guardar".

Tráfico de entorpecentes - Agente que vende substância estupefaciente a policial pensando tratar-se de consumidor - Apreensão que quantidade expressiva de entorpecente por ele guardado - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Alegação do agente no sentido de ser apenas usuário incompatível com o conjunto probatório e com a quantidade de entorpecente apreendida

Realiza o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 o agente que vende substância estupefaciente a policial, pensando tratar-se de consumidor. Ainda que assim não fosse, o próprio estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente não é necessário para caracterizar o tráfico, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aqueles de "manter em depósito" e "guardar". A ulterior alegação de que a substância ilícita se destinaria apenas ao uso próprio não se coaduna com a dinâmica de sua apreensão, devendo ser afastada.

No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Cálculo da Pena - Tráfico de Entorpecentes - Exacerbação da pena-base seguindo os critérios norteadores previstos nos art. 59 do CP em razão da quantidade e a variedade do entorpecente apreendido - Admissibilidade

Nos casos de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06) é perfeitamente admissível a elevação da pena-base com base na variedade e qualidade do tóxico apreendido, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos.

Cálculo da Pena - Tráfico de entorpecentes - Desnecessidade de comprovação de nexos causal entre a conduta do acusado e a circunstância da apreensão ter ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino - Causa de aumento de pena (art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) de natureza objetiva - Reconhecimento

Imperioso o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06 sempre que for constatado que o tráfico de drogas estava sendo praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Em tal situação, torna-se dispensável a comprovação de que o acusado comercializava entorpecentes erigindo diretamente os alunos da escola como público alvo, uma vez cuidar-se de causa de aumento de natureza objetiva." (Ap. nº 0039706-12.2014.8.26.0224; Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 19/05/2016; Data de registro: 19/05/2016) (grifo nosso)

Há, portanto, prova suficiente para reconhecer a autoria do tráfico de drogas.

Apenas para consignar, o esforço da Defesa em desqualificar os depoimentos das testemunhas policiais, embora louvável, não é suficiente para retirar a força probante deles.

Frise-se que os depoimentos dos policiais militares colhidos durante a instrução criminal mostram-se coerentes e harmônicos quanto às circunstâncias em que se deu a ação policial e a localização do entorpecente, além de estar em verdadeira consonância com suas declarações prestadas à Autoridade Policial.

As testemunhas policiais, em uníssono, bem esclareceram de que forma avistaram o acusado, descreveram a conduta do réu que ensejou a abordagem, consignaram não ter sido possível identificar o veículo que estava sendo servido pelo acusado, asseveraram que a droga foi encontrada em poder do réu, mais especificamente em seu bolso e relataram que o réu não estava exatamente em frente ao comércio existente no local.

Apenas para consignar, eventuais contradições no que pertine a aspectos secundários, conforme apontado pelo combativo Defensor, são até normais, dando autenticidade aos relatos, porquanto testemunhas são seres humanos e, como tais, naturalmente suscetíveis a falhas, não sendo tais divergências suficientes para se afirmar que estão mentindo, mormente porque, sobre o fato em si, as narrativas revelam-se uníssonas.

“Pequenas discrepâncias de prova testemunhal explicam-se pelas naturais diferenças de comunicação e pelo fato de terem sido os depoimentos recolhidos em oportunidades diferentes e por pessoas diferentes. (TACRIM-SP-AC nº 162.623 – Rel. Sílvio Lemmi). De outro lado, nenhuma testemunha arrolada exclusivamente pela Defesa foi trazida em Juízo para ser ouvida, a fim de esclarecer os fatos ou, ao menos, contrariar concretamente a versão apresentada pelas testemunhas policiais.

Outrossim, a falta de testemunhas civis que tenham presenciado a abordagem não retira a validade e força probante das declarações prestadas pelas testemunhas policiais. Ressalta-se que é amplamente sabido que testemunhas civis sobre crimes ligados ao tráfico de drogas são muito difíceis de serem levadas perante a Autoridade Policial, pois o medo que impregna a população acerca do mencionado crime é reflexo da estruturação advinda dele, alimentada pelos vultosos lucros conseguidos e pelo chamado “código de ética”, pregado, na maioria das vezes, nos locais mais humildes, o qual, se desobedecido, os colaboradores pagam com a própria vida.

A versão apresentada pelo acusado restou isolada do contexto probatório, devendo-se considerar os demais elementos de convicção existentes e produzidos durante o processo.

Assim, na hipótese, seria mesmo um contrassenso pretender que a versão fornecida pelo acusado sobreponha-se ao depoimento dos policiais encarregados de sua prisão, depoimentos estes que estão em harmonia com as demais circunstâncias que envolvem o delito.

Em outras palavras, impossível seria desmerecer os depoimentos policiais, que sequer conheciam o acusado anteriormente aos fatos, pois são absolutamente aptos e suficientes para embasarem a inequívoca conclusão de que o réu é de fato traficante.

Apenas para consignar, ao contrário do que foi alegado genericamente pela Defesa, não há nada nos autos que pudesse justificar a conclusão de que o réu estaria sendo acusado injustamente da prática do delito de tráfico de drogas.

Dessa forma, por todo o conjunto probatório amalhado, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado e a localização do entorpecente por ele trazido, evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Em arremate, a intenção mercantilista do réu deriva da natureza, variedade e da considerável quantidade e demais circunstâncias em que as drogas e o dinheiro foram apreendidos. De mais a mais, “para caracterização do tráfico de entorpecentes não é indispensável a prova do ato de comércio, podendo ser ele deduzido de elementos variados como as circunstâncias da prisão, a quantidade de entorpecente, o local da infração etc.” (TJRJ – AC 1.327/92 – Rel. Adolphino A. Ribeiro – RDTJRJ 20/310).

Dessa forma, pelas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado,

evidencia-se, pois, a realização do tráfico por ele.

Provas da materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, considerando-se a natureza, a quantidade e a variedade das substâncias apreendidas, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa e as circunstâncias da prisão, a condenação do réu é medida que se impõe." (fls. 121/131)

Passo à nova individualização da pena, considerando o entendimento estabelecido no venerando Acórdão de fls. 199/208 do E. Tribunal de Justiça deste estado de São Paulo e em estrito cumprimento ao determinado na v. Decisão de fls. 354/358 do E.

Superior Tribunal de Justiça, para "reconhecer o direito do agravante à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena do 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, que deverá ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada, nos termos da fundamentação, analisando também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada".

Levando em conta as condições judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, e diante das v. decisões proferidas pela instância superior, a pena-base do réu fica mantida em seu mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas, inexistindo quanto a isso qualquer entendimento diferente das instâncias superiores para este caso, motivo pelo qual fica a pena inalterada nesta etapa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causa de aumento a ser reconhecida, inexistindo entendimento diferente das instâncias superiores para este caso, e em estrito cumprimento à veneranda decisão proferida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de Agravo em Recurso Especial, aplico a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Porém, verifico que, pela natureza e, principalmente, pela considerável quantidade e variedade da droga apreendida (77 porções de cocaína, 26 pedras de crack e cinco porções de maconha), critérios que se mostram decisivos para se estabelecer que, se há que se conceder privilégio ao réu, que seja no mínimo possível, pois, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. (AgRg no HC 698.187/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). Portanto, a diminuição se dará no mínimo legal, ou seja, em 1/6, ficando a pena em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, restando a pena adequadamente modulada e motivada nos termos da fundamentação.

Torno essa pena definitiva na ausência de outras modificadoras, inexistindo entendimento diferente das instâncias superiores para este caso.

Verifica-se, portanto, fixação de pena em patamar superior a quatro anos o que afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Cuidando-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, cujo aspecto altamente nocivo à sociedade em geral ninguém desconhece, por certo que não se afigura socialmente adequada e recomendável à situação a aplicação de penas alternativas ou outros benefícios que, por sinal, implicaria sensação de impunidade e incentivo à prática delituosa, frustrando-se a expectativa social, que exige e espera, em tais condições, efetiva e eficaz resposta à criminalidade cada vez mais crescente, motivos pelos quais fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, sendo ele o único adequado à nova pena fixada.

Finalmente, não há se cogitar da aplicação imediata do disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal nesta seara, vale dizer, sem elementos concretos a respeito do seu comportamento no cárcere, a recomendar a prudência e o bom senso que a questão relacionada à detração penal seja analisada por primeiro pelo Juízo das Execuções.

A lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o Código Penal e não o Código de Processo Penal. A progressão de regime vem, por sua vez,

necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada a progressão, imprescindível que sejam analisados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o do Juízo das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

Nesse sentido:

"Apelação – Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria bem demonstradas – Testemunho dos agentes policiais, sob o crivo do contraditório, ratificando a prova administrativa – Ré confessa, ademais – Não incidência do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos – Precedentes – Pena de multa que se corrige – Mínimo erro material do r. juízo em detrimento da apelante – Regime fechado justificado – Impossibilidade de substituição da física por restritiva de direito – Detração – Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais – Recurso desprovido, com observação." (TJSP - Ap. Nº 0003591-97.2014.8.26.0577 - 4ª Câmara - Rel. Ivan Sartori - J. 28.04.2015 - grifei) Deve-se ressaltar, ainda, que a detração neste momento processual causaria a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, inexistindo entendimento diferente das instâncias superiores para este caso.

Diante do exposto, considerando o que mais dos autos consta, em estrita observância ao entendimento estabelecido no venerando Acórdão de fls. 199/208 do E. Tribunal de Justiça deste estado de São Paulo e em estrito cumprimento ao determinado na v. Acórdão de fls. 354/358 do C. Superior Tribunal de Justiça, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu NICOLAS ORIGUELA MENEZES BADINI, qualificado nos autos, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, considerando-se os malefícios inerentes ao tráfico de drogas ao meio social, destacando-se, ainda, a natureza e variedade, além da grande quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado.

Finalmente, não há qualquer alteração da situação fática ou jurídica que justifique a reconsideração da decisão que decretou a custódia cautelar no presente feito.

Portanto, verifico que ainda estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo de rigor manter a prisão preventiva, cumprindo-se, outrossim, o disposto no parágrafo único do artigo 316 do mesmo diploma legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento do valor apreendido nos autos em favor da União, com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Vicente, 28 de agosto de 2022.

ALEXANDRE TORRES DE AGUIAR
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA